

L'arbitrato al tempo di Giustiniano

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Nel mondo postclassico le costituzioni imperiali riconoscono efficacia obbligatoria e quindi sanzione in via di azione, al compromesso¹.

Si trattava di un negozio atipico, in virtù del quale le parti si obbligavano a demandare la soluzione di una lite ad un arbitro.

Nello stesso accordo, o in una *stipulatio* accessoria si prevedevano poi degli obblighi risarcitori, nell'ipotesi in cui una parte non avesse voluto addivenire ad arbitrato o non avesse voluto sottostare alla decisione dell'arbitro.

A sua volta, in capo all'arbitro era stabilito un obbligo di pronunciarsi, che veniva sanzionato, a certe condizioni dal *Praetor*.

Per avere un'idea più approfondita possiamo rifarci al titolo VIII del IV Libro delle Pandette² in un sunto della traduzione italiana dell'opera del POTHIER³.

Le Pandette definiscono il compromesso come una specie di giudizio che aveva per scopo di terminare le liti, ossia come una convenzione, con cui i litiganti, mediante la comminatoria di una data pena, promettevano di stare alla sentenza di un arbitro che assumeva di giudicare il loro affare.

Il compromesso si definiva pieno quando obbligava tutti i compromittenti e abbracciava tutte le controversie presenti⁴, ma non le future⁵.

Si considerava non pieno ove riguardasse solo una data controversia⁶.

Le condizioni richieste per la sostanza del compromesso erano sostanzialmente: a) che l'affare fosse compromettibile: lo erano tutte le controversie, ma non i delitti infamanti⁷ e

¹ A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, UTET, Torino, 1987, p. 489.

² Commento su Digesto 4, 8 "*De receptis, qui arbitrium receperunt, un sentential dicant*" ("Dei compromessi accettati, e che quelli che accettarono il compromesso, pronuncino sentenza").

³ Cfr. *amplius* R. G. POTHIER, *Le pandette di Giustiniano*, Vol. 1, versione italiana di A. BAZZARINI, Antonio Bazzarini & C., Venezia, 1833, p. 432 e ss.

⁴ E quando contenesse la clausola del dolo, ossia quella clausola in base alla quale ci si possa difendere dal dolo altrui.

⁵ L'arbitro non poteva giudicare di quelle cose che sopraggiungessero dopo la stipulazione della convenzione.

⁶ Poteva definirsi non pieno anche il compromesso in cui si obbligava un solo compromittente, ma i giuristi lo ritenevano inefficace; era ancora non pieno quello che era sfornito della clausola di dolo.

⁷ O quelli, oggetto di giudizio pubblico, in materia di adulterio o di omicidio su commissione.

Per cui se per errore l'arbitrato ne avesse ricompreso uno il pretore avrebbe dovuto impedire che si

le controversie di stato⁸; b) che le parti che compromettevano, potessero farlo⁹; c) che l'arbitro potesse essere tale¹⁰; d) che col compromesso si lasciasse agli arbitri la libera facoltà di proferire sentenza¹¹; e) che col compromesso si lasciasse agli arbitri la facoltà di condurre alla fine l'affare¹²; f) che i compromittenti stabilissero vicendevolmente una pena¹³, a cui dovesse soggiacere colui che non obbedisse alla sentenza o facesse in modo che la sentenza non venisse pronunciata¹⁴.

Al compromesso potevano poi essere apposte delle clausole: a) *purché non intervenga dolo*: la parte che ha agito dolosamente¹⁵ poteva essere chiamata in giudizio con l'azione di stipulazione, e non con l'azione di dolo¹⁶; b) *di protrazione della giornata*: se era stata data all'arbitro la facoltà di protrarre il termine del compromesso¹⁷; c) *che l'arbitro decida tutte le controversie nella stessa giornata*¹⁸; d) *che il compromesso passi all'erede*: poteva essere utile solo se fosse stata clausola reciproca; e) *che l'arbitro possa proferire sentenza in assenza di una o di entrambi le parti*.

Due erano gli effetti principali del compromesso: se l'arbitro lo accettava era obbligato a pronunciare la sentenza; le parti litiganti dovevano scontare la pena stipulata se rifiutavano di accettare la sentenza o se ne impedivano l'emissione.

pronunciasse sentenza ovvero che gli si desse ad essa esecuzione.

⁸ Non in particolare quelle sulla libertà: se ciò fosse accaduto l'arbitro non poteva essere forzato a pronunciare sentenza, perché il dono della libertà esigeva che sopra di essa potessero soltanto pronunciare i giudici superiori. Nemmeno poteva pronunciare ove si trattasse di decidere se un uomo fosse ingenuo (nato da madre libera) ovvero libertino.

⁹ Quelli soltanto che potevano efficacemente obbligarsi, potevano fare compromesso. Così non sarebbe stato efficace un compromesso fatto da un pupillo o da una donna o da un servo.

¹⁰ Non potevano essere arbitri i servi, le donne, i pupilli, i sordi, i muti ed i pazzi, i minori di anni venti, i giudici che dovevano essere chiamati a giudicare dello stesso affare, coloro di cui l'affare fosse proprio.

¹¹ Non sarebbe stato valido un compromesso nel quale si fosse stabilito che Tizio avrebbe fatto sentenza secondo la decisione di Caio; e siccome il pretore non poteva sindacare la sentenza dell'arbitro che fosse pronunciata a suo senno, allora non sarebbe stato possibile che si fissasse in compromesso che l'arbitrato avrebbe dovuto portare ad una determinata decisione.

¹² Per cui gli arbitri dovevano essere sempre in numero dispari e si doveva stabilire in compromesso che in caso di dissenso tra i due arbitri potesse intervenire un terzo.

¹³ Cfr. art. 11 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

¹⁴ La pena non doveva essere per forza una somma di denaro, e poteva essere anche di valore superiore all'affare compromesso; le promesse potevano riguardare beni di differente natura; la promessa poteva essere costituita anche da un nudo patto: nel caso si fosse previsto che chi non obbediva alla sentenza dell'arbitro non poteva più domandare ciò che l'altro gli doveva.

¹⁵ Avesse corrotto l'arbitro o l'avvocato della controparte o avesse ingannato la controparte.

¹⁶ Che era concessa quando non ci fossero altri rimedi. V. A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, op. cit., p. 200.

¹⁷ Ciò consentiva all'arbitro di non incorrere in alcuna pena, se alla fine del termine originariamente imposto non avesse emesso sentenza.

¹⁸ Se aveva anche la facoltà di protrarre la giornata l'arbitro poteva decidere solo alcune controversie ed altre rimandarle.

Il pretore non poteva costringere l'arbitro ad accettare il compromesso ma quando ciò fosse accaduto poteva interporre a fine di costringerlo ad adempiere l'obbligo assunto.

Tale intervento però non era giustificato se il compromesso fosse stato inesistente o nullo dall'origine¹⁹ ovvero quando pur essendo valido, non fosse certo che la pena stipulata si potesse esigere²⁰.

Inoltre il pretore doveva essere sicuro che: a) il compromesso fosse stato accettato dall'arbitro, b) che l'accettazione provenisse da chi assunse le parti di giudice, e promise di por fine alle controversie colla sua sentenza.

Perché se una persona fosse intervenuta nell'affare per tentare di conciliarlo amichevolmente coi suoi consigli o colla sua autorità, non si poteva reputare che avesse accettato compromesso²¹: agli occhi dei Romani pertanto era molto chiara la differenza tra arbitrato e conciliazione; l'arbitro doveva essere uno *iudex* che avesse accettato di giudicare: il conciliatore, al contrario, non aveva alcun obbligo nei confronti delle parti.

Inoltre l'arbitro poteva essere costretto solo se apparteneva ad una magistratura inferiore a quella del pretore, non nel caso fosse anch'esso pretore o di una magistratura superiore come quella del console, perché in tal caso non era soggetto alla sua giurisdizione.

La regola dell'Editto pretorio²² doveva tuttavia essere considerata in modo elastico perché comunque l'arbitro avrebbe potuto addurre valide scuse; così non poteva essere costretto a giudicare se le parti si rivolsero ad un altro arbitro dopo avergli conferito l'incarico e poi fossero tornate successivamente da lui ovvero se fosse sopravvenuto qualche altro impedimento²³ dopo l'accettazione del compromesso, oppure se l'arbitro fosse divenuto sacerdote successivamente all'accettazione²⁴.

¹⁹ Perché ad esempio si fosse impegnata una parte sola e l'altra no.

²⁰ Così non era se la pena fosse stata sotto condizione o avesse cessato la sua funzione per essersi sciolto il compromesso o per scadenza del termine, o per morte o per accettazione (atto di liberazione del debitore), o per sentenza, o per patto.

²¹ *Quod si, inquit, hactenus intervenit ut experiretur an Consilio suo vel auctoritate discuti litem paterentur, non ridetur Arbitrium recepisse. 1. l3 § 2 Ulp. lib. l3 ad Ed.*

²² Editto perpetuo Tit. XIII: "I. Qui arbitrium pecuniam compromissa receperit, sententiam eum dicere cogam". II. *Eumque si ita conventum sit, diem compromissi proferre iubebo*". ("1. Costringerò a pronunciare sentenza colui che ha accettato l'incarico di arbitro d'una lite compromessa. 2. E, se così fu convenuto, gli ordinerò di prorogare il termine del compromesso").

²³ Una causa pubblica o privata, l'accettazione di un incarico pubblico, una malattia (però in tal caso il pretore poteva chiedere di prorogare il compromesso se c'era la clausola che lo avesse permesso).

²⁴ Diversamente doveva emettere sentenza.

L'arbitro poi non poteva essere costretto a giudicare quando era manifesta la sua venalità o la turpitudine.

Gli era addirittura proibito di giudicare quando il compromesso fosse passato all'erede²⁵ perché se quegli che aveva fatto il compromesso col defunto avesse mosso controversia sull'eredità, una sentenza che venisse proferita dall'arbitro avrebbe portato pregiudizio alla questione della eredità; per conseguenza in tal caso l'arbitrato doveva essere sospeso sino a quando non si fosse concluso il giudizio per la petizione di eredità.

Se nel compromesso era poi stabilito il giorno della pronuncia l'arbitro doveva sentenziare come indicato; se invece il giorno non fosse stato stabilito doveva procurare di stabilirlo con il consenso delle parti, perché diversamente poteva essere chiamato a pronunciare in qualsiasi tempo.

Non andava però individuato un giorno in cui un giudice non potesse essere tale²⁶.

In ogni caso non poteva essere costretto a pronunciare l'arbitro che ritenesse di non avere ancora cognizione piena della causa, perché ciò sarebbe andato contro il principio di equità che imponeva in tal caso fosse fissata una dilazione.

Parimenti se gli arbitri fossero stati più, non poteva costringersi uno solo a pronunciare la sentenza, ma dovevano decidere tutti, o nessuno, a meno che il compromesso non avesse stabilito la possibilità di una pronuncia degli uni in assenza di altri.

Se l'arbitro cercava di nascondersi, il pretore doveva farlo rintracciare; e se non si faceva vedere dopo un certo tempo, doveva condannarlo ad una multa.

Il pretore doveva poi assicurarsi che la pronuncia coprisse tutte le controversie per cui si fosse stipulato il compromesso.

S'incorreva nella pena stipulata se s'impediva all'arbitro di giudicare: così se non ci si presentava alla pronuncia della sentenza. Le parti potevano essere convocate per lettera o per messo²⁷; anche se avessero voluto presenziare a mezzo dei procuratori l'arbitro poteva

²⁵ In base alla clausola che il compromittente avesse inserito nel compromesso.

²⁶ Ad esempio in un giorno di ferie. Ma se l'arbitro avesse deciso in giorno di ferie su richiesta del pretore la sentenza era valida.

²⁷ Il luogo doveva essere quello individuato in compromesso; diversamente le parti potevano non ubbidire. Se in compromesso il luogo non era ben individuato si faceva riferimento a quello di stipulazione. Comunque il luogo doveva essere di facile accesso per le parti e non un luogo disonesto: così se l'arbitro avesse dato loro appuntamento in una taverna od in un lupanare ove le parti non avrebbero potuto entrare per salvaguardare il loro decoro, essi potevano rifiutare di andarvi.

costringerli a presenziare personalmente²⁸. Ma anche se si partecipava e si avesse deferito la causa al giudice ordinario, si era soggetti alla pena stipulata e la causa proseguiva altrove.

La sentenza dell'arbitro andava osservata anche se non fosse stata equa²⁹, ma ciò non valeva per la sentenza ingiusta, ossia quella che andava contro le condizioni indicate in compromesso; per sentenza ingiusta si intendeva quella emessa su un affare diverso da quelli specificati in compromesso³⁰ oppure quella pronunciata fuori termine o non pronunciata di fronte alle parti³¹ o ancora quella, se nominati tre arbitri, che fosse pronunciata in assenza di uno di essi³².

In tali casi chi disubbidiva alla sentenza non poteva essere sottoposto al pagamento della pena stipulata.

Come era lecito disubbidire ad una sentenza ingiusta così era possibile disubbidire ad una sentenza incerta in cui fossero contenute statuizioni del tipo: *"Pagherai quanto gli devi"* oppure *"È deciso che dobbiate stare alla vostra divisione"* o ancora *"Riceverai in ragione di quella parte che pagasti ai tuo creditori"*; lo stesso valeva nel caso di sentenza disonesta.

Si doveva invece ubbidire qualora l'arbitro avesse deciso con dolo malo, ma qualora non lo si fosse fatto e si fosse convenuti con l'azione di stipulazione, si poteva opporre l'*exceptio doli mali*³³.

Se la sentenza dell'arbitro conteneva una condanna bisognava prestare quanto imposto dall'arbitro entro il termine stabilito nel compromesso; se non vi era termine l'arbitro

²⁸ *Arbiter adesse litigatores vel per nuntium vel per epistolam jubere potest.* 1. 49 § » Julian. lib. 4 Digestus. *Si dominem qui invicem stipulati sint, procuratores suos agere apud Arbitrum velint, potest ipsos jubere etiam adesse.* 1. 3a § 18 Paul. lib. I 3 *ad Edictus*. Come vedremo ritroveremo questi precetti anche nella legislazione successiva del conciliatore del 1892.

²⁹ Non poteva però essere contraria alle Leggi.

³⁰ All'arbitro era lecito fare solo ciò che era contenuto nel compromesso: non poteva pronunciare a suo talento o sopra un affare qualunque.

³¹ Sono casi di nullità della sentenza. Peraltro non poteva dirsi che le parti fossero presenti se una delle due fosse stato un pupillo senza la presenza del tutore, oppure un pazzo (il "furioso" per Pomponio era considerato come assente). Erano però dati per presenti i sordi ed i muti perché si riteneva che in qualche modo potessero interloquire.

³² Sempre che il compromesso non prevedesse la sentenza disgiunta. Ma nel caso di sentenze disgiunte tutte diverse? Prevaleva quella per la somma più bassa perché su quella erano tutti d'accordo.

³³ Ed in presenza della clausola di dolo inserita in compromesso si poteva chiamare in giudizio chi aveva corrotto l'arbitro.

doveva fissare un termine modico specie se il creditore non avesse avuto interesse ad un pagamento immediato³⁴.

La sentenza dell'arbitro poteva anche proibire di domandare qualcosa ad una delle parti o ad un terzo³⁵; in tal caso chi domandava incorreva nella pena³⁶.

Sull'effetto della sentenza arbitrale c'era all'epoca discordanza: per le Pandette essa si limitava a far incorrere nella pena stipulata chi non vi ubbidiva, ma non produceva l'azione o l'eccezione della cosa giudicata: quindi non era nemmeno appellabile.

Per le Costituzioni di Giustiniano al contrario quando le parti stipulavano un compromesso giuravano di osservarlo³⁷ o facevano giurare l'arbitro, e da ciò nasceva il diritto di azione per l'attore e di eccezione per il convenuto.

Le Novelle³⁸ vietavano invece il compromesso con giuramento³⁹.

Il compromesso si scioglieva con la morte di una delle parti⁴⁰ o con la morte dell'arbitro, per decorrenza del termine in esso prescritto, per intervenuta transazione sull'affare che ne era oggetto, per morte del servo oggetto di compromesso⁴¹, per rimessione di una parte all'altra della pena stipulata, per assunzione della qualità di legato successivamente alla stipulazione del compromesso in assenza di interesse a continuare il procedimento⁴², per inefficacia dell'obbligazione a seguito della cessione dei propri beni⁴³.

³⁴ Se il condannato interpellato non pagava e quindi finiva in mora, doveva prestare quanto pattuito nella pena: quando avesse adempiuto alla sentenza sarebbe stato liberato dalla pena, sempre che l'arbitro però non avesse fissato il termine perché, in tal caso, non c'era liberazione.

La parte che non pagava in un dato giorno per impedimento del suo creditore o di altro impedimento imprevedibile, era liberato dalla pena; ma se in progresso il creditore fosse stato disponibile a ricevere il pagamento ed il debitore non avesse adempiuto, quest'ultimo andava soggetto alla pena.

³⁵ Ad esempio al fideiussore di una delle parti.

³⁶ Se l'arbitro pronunziò non sembrare che Tizio fosse debitore di Sejo, quest'ultimo non avrebbe potuto domandare a Caio senza disubbidire alla sentenza; se l'arbitro avesse proibito che una parte domandasse all'altra, non avrebbe potuto farlo nemmeno l'erede di una delle parti, perché compito degli arbitri era quello di terminare le liti e non di prorogarle.

³⁷ Od in sostituzione lo sottoscrivevano.

³⁸ Pubblicate il 5 gennaio del 535 a.C., successivamente alla pubblicazione del *Corpus iuris civilis*.

³⁹ Novella LVXXXII, cap. 2

⁴⁰ Se non c'erano riferimenti agli eredi o ad altri successori.

⁴¹ A meno che le parti non avessero conservato comunque qualche interesse alla sentenza.

⁴² Per difendersi. I legati nel tempo della legazione non potevano promuovere azioni se non per difendersi da ingiurie.

⁴³ In tal caso non poteva essere né attrice né convenuta. Si fa probabilmente l'ipotesi in cui si fosse stati autorizzati dal pretore a farlo, cosa che poteva accadere quando l'insolvenza non fosse addebitabile al debitore.

Se il compromesso infine veniva sciolto l'arbitro cessava di essere tale, cosa che si verificava anche quando fosse stata resa sentenza⁴⁴.

Non si confonda l'istituto del compromesso con l'arbitraggio (che i Romani definivano *arbitratus*) e quindi l'arbitro con l'arbitratore che è pure presente nel mondo romano.

L'arbitraggio veniva in considerazione quando le parti demandavano ad un terzo (e quindi non al debitore o al creditore), la determinazione dell'oggetto contrattuale (qualità, prezzo ecc.).

Nelle fonti si parla, a quest'ultimo proposito, di *arbitrium merum* (libero apprezzamento) e di *arbitrium boni viri* (apprezzamento da commisurarsi ad un criterio obiettivo di equità): nella prima ipotesi se non c'era la determinazione di un terzo il contratto era nullo; nella seconda ipotesi la determinazione dell'oggetto veniva fatta da un terzo di buona esperienza (o anche da una delle parti) e se tale terzo (o la parte incaricata) non usava la buona diligenza o non faceva la determinazione, si poteva passare alla fase giurisdizionale⁴⁵.

⁴⁴ Essa poteva prestarsi a correzione solo quando nel compromesso si fosse prescritto che l'arbitro avrebbe dovuto decidere tutte le questioni al medesimo tempo.

⁴⁵ Cfr. anche A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, op. cit., p. 564.